

- Expediente nº.: **EXP202309925**
(PS/00407/2023. RR/0065/2024)

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN

Examinado el recurso de reposición interpuesto por **ALL IN DIGITAL MARKETING, S.L.** (en lo sucesivo, la parte recurrente) contra la resolución dictada por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos de fecha 10 de septiembre de 2024, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 10 de septiembre de 2024, se dictó resolución por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el expediente EXP202309925, en virtud de la cual se imponía a **ALL IN DIGITAL MARKETING, S.L.** una sanción de multa de TRES MIL EUROS (3.000 €), por la comisión de una infracción del Artículo 21 de la LSSI, tipificada en el Artículo 38.4.d) de la LSSI.

Dicha resolución, que fue notificada a la parte recurrente en fecha 3 de octubre de 2024, fue dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), y supletoriamente en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP), en materia de tramitación de procedimientos sancionadores.

SEGUNDO: Como hechos probados del citado procedimiento sancionador, PS/00407/2023, quedó constancia de los siguientes:

“**PRIMERO:** Tal y como reconocen las partes reclamante y reclamada, el reclamante **A.A.A.**, se registró en la web allzone.es el día 01/02/2023, para la realización de su pedido referencia *****REFERENCIA.1**, realizando una contratación online de un ordenador portátil el día 22/02/2023, a través de la web de la reclamada, en la que aceptó todas las condiciones generales de compra, y política de privacidad.

SEGUNDO: Tal y como reconocen las partes reclamante y reclamada, el reclamante solicita en una primera ocasión la baja en la suscripción a boletín de noticias y ofertas asociadas el día 20/03/2023. Pero el día 23/03/2023 vuelve a recibir una comunicación electrónica referida a la participación de un sorteo remitida por ALL IN ZONE.

TERCERO: Tal y como reconocen las partes reclamante y reclamada, el mismo día 23/03/2023, el reclamante vuelve a solicitar la baja, clicando la opción de “cancelar suscripción” que aparece el email de oferta recibido dicho día 23/03/23, como opción gratuita puesta a disposición del cliente para que cancele su suscripción a boletín y ofertas asociadas en el momento que lo desee.

CUARTO: Constan aportados por el reclamante los siguientes correos electrónicos cuya remisión es reconocida por la reclamada, todos los cuales se remiten tras la solicitud de baja del boletín de noticias y ofertas realizada el 23 de marzo de 2023: 23 de marzo, 28 de marzo, 13 de abril, 17 de abril, 20 de abril, 25 de abril, 2 de mayo, 11 de mayo, 16 de mayo de 2023, así como los días 8, 15, 16, y 22 de junio de 2023. Todos ellos aparecen remitidos desde la dirección allzoners@allzone.es dirigidos a la dirección electrónica *****EMAIL.1** perteneciente al reclamante, y se invita al mismo a participar en diversos sorteos de productos o servicios, conteniendo al final de cada email un link que permitiría en principio cancelar la suscripción a estos correos”.

TERCERO: La parte recurrente ha presentado en fecha 24 de octubre de 2024, en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición, que contiene un análisis de la prueba aportada en el procedimiento sancionador dividido en 8 apartados, casi idéntico al que fue realizado en los escritos de alegaciones a la Propuesta de Resolución y el escrito previo que fue presentado el 24-1-24 durante la fase de prueba, cuya única diferencia con el último escrito de alegaciones a la Propuesta de Resolución de 15-5-24 son las precisiones o aclaraciones realizadas con un asterisco en los apartados 5 y 7 de su escrito de recurso, y la aportación de un nuevo documento (Documento 6), junto con los anteriormente aportados (Documentos 1 a 5).

En concreto, junto con el recurso se aportan los siguientes documentos:

- Informe acerca del procedimiento de compra realizado por el reclamante, detallando los pasos a seguir para adquirir el producto DOC1.
- Política de privacidad, DOC 2.
- Captura pantalla de registro de cliente en la web, DOC 3.
- Ficha completa del cliente, DOC4.
- Pantalla de impresión de todos los datos obrantes en su entidad asociados al reclamante, DOC 5.“
- Captura de pantalla del área de clientes donde, según la recurrente: *se puede ver específicamente el lugar del cual el cliente puede activar y desactivar su consentimiento a recibir o no comunicaciones comerciales desde la web reclamada*”. DOC 6.

En base a ello, la entidad recurrente suplica que: *“Que, acogiendo nuestras alegaciones, reponga la resolución que se recurre, estimado el recurso, dictando otra por la que se deje sin efecto la sanción impuesta, y en todo caso PARALICE LA EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN HASTA AGOTAR TODA VÍA ADMINISTRATIVA O CONTENCIOSAADMINISTRATIVA.”*

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I Competencia

Es competente para resolver el presente recurso la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP) y el artículo 48.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en lo sucesivo, LOPDGDD).

II

Contestación a los motivos alegados en el escrito de recurso

Cabe desestimar las manifestaciones efectuadas por la parte recurrente, reiterándose básicamente en las alegaciones y documentos ya presentadas a lo largo del procedimiento sancionador, y aportando un nuevo documento (Documento 6) que fue requerido y no aportado durante el procedimiento originario, en base a los siguientes motivos:

Primero: Aclaración preliminar sobre el motivo de impugnación de la Resolución.

Primeramente, cabe aclarar que el recurso presentado no hace referencia expresa a la concurrencia de los motivos en base a los cuales se solicita que se proceda a la impugnación de la resolución que fue dictada el 10 de septiembre de 2024, y a la no imposición de sanción, solicitando que se paralice la ejecución de la resolución.

Así pues, el recurso es más bien un escrito de contestación al requerimiento de prueba que fue realizado mediante acuerdo dictado por la instructora con fecha de 18-1-24, en el que la recurrente dedica 7 apartados a indicar los documentos que se aportan al objeto de cumplir con cada requerimiento de información realizado en dicho acuerdo, y otro motivo (contenido en el apartado 2) referido a las razones por las que entiende que las “evidencias digitales” que se aportan deben ser admitidas como prueba, por entender que éstas tienen plena validez legal. Argumentos, que como ya se ha adelantado, se contenían ya en el escrito de alegaciones a la Propuesta de Resolución, y habían sido ya desestimados en la Resolución recurrida.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la LPACAP, es requisito de admisión del recurso el señalar el motivo de impugnación de la resolución recurrida. Señala así dicho precepto lo siguiente:

“Artículo 115. Interposición de recurso.

1. La interposición del recurso deberá expresar:

- a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo.*
- b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación.*
- c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones.*
- d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación.*
- e) Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.”*

El recurso presentado, tras reiterarse en la aportación de los mismos 5 documentos que fueron aportados al procedimiento, añadir dos precisiones aclaratorias, y aportar un documento más, no se pronuncia expresamente acerca del motivo de impugnación, limitándose a indicar lo siguiente: *“En base a ello, SUPLICO que, acogiendo nuestras alegaciones, reponga la resolución que se recurre, estimado el recurso, dictando otra por la que se deje sin efecto la sanción impuesta, y en todo caso PARALICE LA EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN HASTA AGOTAR TODA VÍA ADMINISTRATIVA O CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.”*

No obstante, pese a no realizarse una referencia expresa al motivo por el cual se impugna la resolución (razón de su impugnación), del escrito puede deducirse que lo que pretende la recurrente es impugnar la valoración de prueba que fue realizada en la Resolución recurrida, y solicitar que la misma sea revisada, y se declare la exención de responsabilidad la entidad reclamada, por haber acreditado que la misma no cometió la infracción tipificada en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en adelante, LSSI), puesto que cumplió con el requisito de recabar el consentimiento del reclamante para poder remitirle las comunicaciones comerciales a las que se refería el procedimiento. Toda vez que el artículo 21.1 de la LSSI, cuya infracción fue imputada y se entendió cometida por la parte recurrente, señala lo siguiente:

“Artículo 21. Prohibición de comunicaciones comerciales realizadas a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.

1. Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas”.

Segundo: Sobre los hechos controvertidos del procedimiento.

En segundo lugar, para entender las manifestaciones realizadas por la recurrente en torno a la valoración de la prueba, es necesario partir de la fijación de los hechos controvertidos que fueron objeto de determinación durante el periodo de prueba del procedimiento:

- No fueron nunca hechos controvertidos ni las dos solicitudes de baja/oposición que fueron realizadas por el reclamante a recibir comunicaciones electrónicas de la reclamada, ni el hecho de que ésta le remitiera 13 comunicaciones posteriormente a esta solicitud.

Tal y como se hizo constar en los hechos probados del procedimiento, reclamante y reclamada coinciden al señalar que el reclamante adquirió un ordenador de la reclamada en febrero de 2023, y tras recibir correos electrónicos comerciales dirigidas por la parte recurrente, accedió al link de cancelación de suscripción que constaba en los mismos, y se opuso en dos ocasiones a la recepción de comunicaciones comerciales de la reclamada (20 y 23 de marzo de 2023). Y se ha reconocido por ambas partes que, posteriormente a ello, el reclamante recibió nuevos correos electrónicos en los que la reclamada le invitaba a participar en sorteos (23 de marzo, 28 de marzo, 13 de abril, 17 de abril, 20 de abril, 25 de

abril, 2 de mayo, 11 de mayo, 16 de mayo de 2023, así como los días 8, 15, 16, y 22 de junio de 2023).

- El hecho controvertido principal, en cuya acreditación se centró el acuerdo de prueba de 18-1-24, se refería únicamente a acreditar si eran ciertas las manifestaciones realizadas por la reclamada de que las comunicaciones electrónicas remitidas tras la solicitud de baja (oposición) se remitieron con el consentimiento del reclamante, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.1 de la LSSI. Toda vez que, según la entidad reclamada:

“ALL IN ZONE ha tramitado y hecho efectivas todas las solicitudes de cancelación de la suscripción al boletín de noticias que ha realizado el reclamante desde su registro inicial (20/03/23 y 23/03/23), siendo remitidas las comunicaciones electrónicas posteriores debido a que el reclamante volvió a darse de alta del servicio el mismo en tres dos ocasiones posteriores a las solicitudes de baja, (22 de marzo de 2023, y 25 de marzo). En su virtud, el correo de 23 de marzo se remitió puesto que tras darse de baja dicho día solicitó el alta el mismo día, y las notificaciones posteriores al 25 de marzo de 2023 pueden estar produciéndose porque el cliente volvió a solicitar el alta con dicha fecha, sin haber vuelto a solicitar la baja”.

Por este motivo, el acuerdo de prueba de 18-1-24 se centró en requerir a la reclamada -a través de 7 puntos diferentes- que aportase información acreditativa que permitiera conocer cómo están arbitrados los mecanismos de obtención del consentimiento en su proceso de venta online y en el servicio de alta-baja del boletín de noticias y ofertas mediante el cual se accionaba la remisión de comunicaciones comerciales, y, acreditar que la empresa obtuvo el consentimiento del reclamante para remitir todas las comunicaciones electrónicas que constan en el presente expediente. Toda vez que la acreditación de este previo consentimiento del reclamante, sea digital o en papel, sería una eximente de responsabilidad puesto que demostraría que la remisión de comunicaciones no estaba prohibida, al haberse solicitado de nuevo la remisión de comunicaciones comerciales al clicarse el alta en dicho boletín desde el área web.

Pues bien, la reclamada contestó a dicho acuerdo de prueba el 24-1-24 mediante un escrito que es reproducción literal exacta del posteriormente presentado como escrito de alegaciones a la Propuesta de Resolución del procedimiento, cuyos argumentos se vuelven a reproducir de nuevo literalmente en el presente recurso, con pequeñas variaciones y aportando un nuevo documento que no fue aportado en fase de prueba (Documento 6: Captura de pantalla área cliente web), que no consta fechado.

Así pues, habiéndose practicado prueba que pudiera determinar si era cierto que el reclamante había manifestado su consentimiento a recibir estas comunicaciones, tanto la Propuesta de Resolución como la Resolución impugnada estimaron que la reclamada, (ahora recurrente): (i) había acreditado que contaba con el consentimiento inicial del reclamante para recibir comunicaciones comerciales que se refieran a productos similares al que fue adquirido el 22-2-23 (ordenador portátil), aunque ello no le habilitaba para remitir todas las comunicaciones comerciales que le fueron remitidas (por ejemplo, en relación a viajes) (ii) pero no acreditó que tras haber solicitado la baja de estas comunicaciones el 20 y 23 de marzo de 2023, el reclamante solicitase de nuevo el alta con fechas de 22 y 25 de marzo de 2023, puesto que no se aporta

evidencia alguna de que el mismo marcase la referida casilla del boletín de noticias y ofertas dentro de su área de cliente.

Tercero: Sobre la valoración de la prueba que ya fue aportada al procedimiento como Documentos 1 a 5.

Procede, por tanto, centrar el objeto de este recurso y la resolución del mismo en determinar si la recurrente aporta motivos y documentación que permita impugnar la valoración de prueba realizada en la Resolución, y entender que cabe impugnar la misma, por derivarse de dicha prueba que la recurrente no incurrió en la infracción del artículo 21.1 de la LSSI.

Principalmente, como se ha dicho, el escrito de recurso es una reproducción literal de los 8 apartados contenidos en el último escrito que fue presentado en el procedimiento (alegaciones a la Propuesta de Resolución de 15/05/2024), donde la entidad reclamada se limitaba a contestar al requerimiento de documentación que fue realizado mediante el acuerdo de prueba de 18/01/2024, señalando uno a uno los documentos que aportaba para acreditar cada uno de los 7 aspectos cuya información había sido requerida. Y aporta, de nuevo, los 5 documentos que habían sido ya presentados en el procedimiento (en más de una ocasión). Respecto de los cuales, repite los mismos argumentos, añadiendo una precisión o aclaración nueva en el apartado 5º del recurso.

En este sentido, es importante recalcar la importancia que tiene en este caso la obligación de documentar y poder acreditar la concurrencia del consentimiento, que se impone a todo prestador de servicios de la información. Tal y como señalaba expresamente la Resolución del procedimiento, en su Fundamento de Derecho III:

<<En este sentido, no cabe duda de que -tal y como señala la Propuesta de Resolución- es la reclamada la que ostenta la carga de la prueba para acreditar que el reclamante prestó su consentimiento a recibir nuevas comunicaciones electrónicas, solicitando el alta los días 22 de febrero de 2023 (al adquirir el ordenador) y posteriormente los días 22 y 25 de marzo de 2023 (al activar el alta del boletín), puesto que la existencia de estos 3 consentimientos o solicitudes sería un hecho controvertido que podría ser impositivo, extintivo, o excluyente de la responsabilidad, alegados por la misma. Máxime cuando ésta es la única que está en disposición de acreditar las presuntas activaciones de alta en el boletín de noticias que generan las comunicaciones comerciales sobre las que versa este procedimiento, toda vez que éstas se realizan utilizando su plataforma web, siendo esta la que está obligada a documentar el consentimiento del cliente.

Por tanto, es obligación de la reclamada, como prestadora de servicios de la sociedad de la información que celebra contrataciones electrónicas y remite comunicaciones comerciales electrónicas a quienes hayan contratado sus productos o servicios, el documentar, registrar y conservar dichos consentimientos.

Pues bien, vistos los 8 argumentos contenidos en el recurso, se observa, primeramente que los argumentos contenidos en los apartados 1, 3, y 8 del recurso

fueron admitidos en su día y se han considerado como hechos probados no controvertidos en el procedimiento, toda vez que se refieren al hecho de contratación por el reclamante del producto que fue adquirido el 22-2-23, cuyo consentimiento no se cuestiona, ni imputa en el presente procedimiento. No constando en la Resolución pronunciamiento alguno a la falta de dicho consentimiento contractual y aceptación de las condiciones y política de privacidad.

En relación con los demás motivos que son reproducción literal de los que fueron ya analizados y desestimados en la Resolución, cabe confirmar la valoración de la prueba realizada en la misma, que se considera ajustada a derecho.

- Así pues, se solicita (apartados 4 a 7 del recurso) la admisión como prueba de la captura de pantalla de la ficha del cliente aportada como Documento 4, a los efectos de acreditar con ello que el reclamante solicitó el alta del boletín los días 22 y 25 de marzo de 2023, prestando su consentimiento a recibir nuevas comunicaciones comerciales.

Repite la recurrente el argumento de que con este documento ha contestado al requerimiento de la siguiente información que fue solicitada en fase de prueba: (i) la justificación de todas las altas y bajas del boletín solicitadas por el reclamante; (ii) los logs acreditativos de que dichas solicitudes de alta se produjeron, y su interpretación; (iii) y la dirección de IP desde la que se realizaron tales solicitudes. Y pide que sean “admitidos como prueba”, realizando dos nuevas precisiones en los apartados 5 y 7 con la intención de reforzar este argumento.

Cabe aclarar que los 5 documentos aportados (incluida la captura de la ficha de cliente aportada como Documento 4) fueron admitidos como prueba en el procedimiento, y por ello fueron tenidos en cuenta y valorados tanto en la Propuesta de Resolución como en la posterior Resolución. Cuestión distinta es que la valoración de la prueba realizada en los Fundamentos de Derecho III y IV de la Resolución considerase que las capturas de pantalla no eran una prueba suficiente para acreditar que el reclamante prestó su consentimiento a recibir comunicaciones comerciales, máxime cuando el hecho de haber solicitado el alta fue negado expresamente por el mismo.

Al respecto, cabe considerar ajustada a derecho la valoración realizada en la Propuesta y la Resolución del procedimiento sancionador, toda vez que la captura de pantalla de la ficha del cliente aportada como Documento 4, es un documento interno que refleja la captura de pantalla de un registro de la base de datos de la empresa, en el que aparecen las presuntas fechas de alta y baja del boletín solicitadas por el reclamante. Así mismo, siendo un documento sin fecha, se desconoce a qué momento pertenece, y también si los datos registrados en la misma son susceptibles de modificación manual por el personal de la empresa.

Tal captura de pantalla de la ficha de cliente carece de eficacia probatoria para acreditar, por sí sola, que el reclamante solicitó el alta del boletín en las fechas

que constan en la misma, y por tanto, no sirve para acreditar de forma fehaciente y objetiva que el mismo prestase su consentimiento a recibir comunicaciones comerciales. Tal y como señaló el Fundamento de Derecho III:

<<(…) Durante la instrucción, se acordó abrir un periodo de prueba requiriendo a la reclamada cierta documentación al objeto de comprobar la certeza de estas altas (solicitudes de comunicaciones comerciales), contestando la reclamada el 24 de enero de 2024, mediante un escrito en el que realizaba alegaciones y aportaba solo parte de los documentos requeridos. Si se aportan 3 documentos requeridos en el acuerdo de prueba, como el documento 1 (explicativo del proceso de contratación online), la política de privacidad (documento 2) y los datos registrados del cliente (documento 5), pero ninguno de ellos acredita que el reclamante solicitase la recepción de estos correos comerciales. El resto de documentos aportados son capturas de pantalla (en adelante, pantallazos) de su sistema informático, que no pueden servir como justificación documental del consentimiento por los motivos que seguidamente se expresarán.(…)

(…) Así pues, de acuerdo con lo mantenido de forma reiterada por la jurisprudencia, en Sentencias como la SAN 2875/2016, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de 15 de julio de 2016, que mantiene lo siguiente: “En cuanto a la impresión del registro de pantalla en la página web www.lotonazo.com. en el año 2005, lo cierto es que esta Sala ha declarado en la Sentencia de 9 de abril de 2008 -recurso nº.235/2006 -, que los pantallazos o reflejos informáticos no acreditan la prestación del consentimiento: “...no se trata más de un simple “pantallazo” informático, que nada acredita ni aporta ninguna información relevante a la hora de poder acreditar el consentimiento del titular de los datos”. En igual sentido se pronuncia la Sentencia también de esta Sala de 17 de marzo de 2015 -recurso nº. 103/2014”.”>>

- Por otra parte, cabe desestimar, nuevamente, el argumento contenido en el apartado 2º del escrito de recurso (contenido así mismo en los escritos de alegaciones a la propuesta de resolución y de aportación de prueba), que insiste en que en un proceso de contratación online cabe dotar de validez legal a las evidencias “digitales” que la misma aporta (capturas de pantalla de la ficha de cliente) ante la imposibilidad de firmar por escrito los documentos. Entendiendo conforme a derecho la motivación dada al respecto en el Fundamento de Derecho IV de la Resolución, que señala:

<< Al respecto, cabe señalar que la reclamada parte de un error esencial en su argumentación, pues la suscripción del boletín (solicitud de recepción de comunicaciones comerciales según el artículo 21 de la LSSI) no puede ser calificada de contratación de servicios, puesto que para que exista un contrato entre partes -electrónico o en papel- deberán concurrir los requisitos establecidos en el artículo 1261 del Código Civil, que dispone lo siguiente: “No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes:

- 1.º Consentimiento de los contratantes.*
- 2.º Objeto cierto que sea materia del contrato.*
- 3.º Causa de la obligación que se establezca”*

(…) En este supuesto, no estamos en la presencia de un contrato que active el boletín, sino ante el cumplimiento de un requisito legal por parte de la entidad reclamada en su calidad de prestadora del servicio de la sociedad de la información consistente en la remisión de comunicaciones electrónicas, que está generalmente

prohibida por el artículo 21 de la LSSI, exigiendo para su posible realización que exista previo consentimiento del interesado.

Cuando el acuerdo de inicio y la propuesta de resolución del presente procedimiento sancionador se refieren a que la reclamada debe acreditar que el reclamante dio su consentimiento para recibir nuevas comunicaciones comerciales -accionando la casilla del boletín desde su área de cliente en la web- en las fechas alegadas por la reclamada (20 y 23 de marzo de 2023), se pretende comprobar si la reclamada ha cumplido con el requisito legal del previo consentimiento para recibir comunicaciones comerciales. Toda vez que este es requisito del artículo 21 de la LSSI cuyo incumplimiento implicaría que los 13 correos comerciales que le remitió al reclamante -tras haberse éste opuesto a su recepción accionando el link de baja en dos ocasiones- supusieron una infracción de la prohibición prevista en el artículo 21.1 de la LSSI. Y en este sentido, el consentimiento puede ejercerse presencialmente mediante la firma manuscrita de documentos, o por medios electrónicos o digitales, pero en todos los casos, el prestador del servicio estará obligado a acreditar que dispone del mismo, lo que le obliga a documentarlo adecuadamente, puesto que: (i) solo al que remite las comunicaciones comerciales se le imputa la obligación de recabar este consentimiento en la LSSI; (ii) la reclamada está obligada legalmente a acreditar que ha recabado dicho consentimiento, como responsable del tratamiento de los datos personales que supone la remisión de este tipo de correos electrónicos (en base a lo dispuesto en los artículos 7 y 4.2 del RGPD, así como 5.2 del RGPD, (iii) y, a su vez, es el responsable de la plataforma web que acciona la remisión de comunicaciones comerciales a través del boletín, por lo que solo la reclamada está en disposición de arbitrar un adecuado sistema o mecanismos que sea capaz de acreditar que el interesado prestó su consentimiento a recibir dichas comunicaciones, registrándolo y archivándolo con la garantías necesarias que permitan asegurar que fue el interesado quien otorgó dicho consentimiento de forma libre, específica, informada e inequívoca, en las fechas durante las cuales se han remitido los citados correos.

En el presente supuesto, la reclamada no aporta ninguna justificación del consentimiento, presuntamente prestado por el reclamante para recibir de nuevo estas comunicaciones, no considerándose como tal la captura de pantalla de la ficha de cliente, por los motivos que fueron expuestos en la Propuesta de Resolución de este expediente.(...)>>

La aportación de la ficha de cliente que consta en el Documento 4 se realizó por la reclamada durante la fase de alegaciones al Acuerdo de Inicio. No considerándose suficiente para acreditar que las fechas de alta y baja que constan en la misma se correspondían con la realidad, el acuerdo de prueba de 18-1-24 requirió diversos documentos que podrían constituir indicios racionales o evidencias informáticas de que las anotaciones que constan en la ficha (fechas de alta y baja del boletín) se habían generado automáticamente por el sistema al marcar la casilla de alta del boletín desde el área de cliente web al que, según la reclamada, había accedido el reclamante.

- Por lo que respecta a los apartados 5 y 6 del recurso, cabe señalar que los mismos responden al requerimiento de prueba realizado para aportar documentación que pudiera justificar la trazabilidad del sistema, y comprobar que las fechas de alta y baja que constaban en la ficha de cliente se correspondían con la realidad. En concreto, se requirió la acreditación de los logs y direcciones

de IP generados al registrarse y solicitar el alta y baja del boletín, sin que la reclamada los aportase en su momento.

Pues bien, en los apartados 5 y 6 del recurso, la recurrente insiste en que la acreditación de estos dos datos consta en la propia ficha de cliente aportada como Documento 4.

Vistas las manifestaciones realizadas en dichos apartados, y no aportándose documento adicional alguno para acreditar ambas cuestiones, cabe llegar a la misma conclusión a la que llegó la Resolución del procedimiento, toda vez que:

- En el apartado 5 del recurso, en el que se contesta al requerimiento de aportación de: *“Captura de pantalla de sus sistemas donde se visualicen los logs de las solicitudes de la parte reclamante de alta en la suscripción de los boletines de noticia, e interpretación de dichos logs”*.

La entidad recurrente vuelve a manifestar que aporta la misma ficha completa del cliente donde constan dichos logs como Documento 4, y añade el siguiente comentario que no constaban en ninguno de los escritos presentados en el procedimiento sancionador: *“*Cabe destacar que la aportación de logs que hacemos está totalmente relacionada con las fechas de alta y baja en la suscripción y por lo tanto se debería considerar prueba suficiente”*.

De acuerdo con el “Glosario de términos en materia de ciberseguridad” publicado por el Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), los logs son registros de eventos de la actividad de los usuarios y de los procesos asociados a dicha actividad, como pueden ser el inicio/ salida de sesión, tiempo de actividad o conexiones, entre otros. Existen diversos tipos de logs, puesto que estos pueden generarse por sistemas operativos, por aplicaciones, por equipos de red, o de seguridad.

Es cierto que las fechas de alta y baja que aparecen en el apartado “conexiones” de la la ficha de cliente coinciden con las que señaló la reclamada desde el inicio del procedimiento sancionador, pero éstos no se corresponden con los logs que fueron requeridos en fase de prueba (*logs de las solicitudes de la parte reclamante de alta en la suscripción de los boletines de noticia, e interpretación de dichos logs*).

Así pues, dentro de este apartado de la ficha de cliente, constan unos logs automáticos generados por el sistema operativo en el que se hacen constar las conexiones realizadas, incluyendo los siguientes campos: ID/ FECHA/ PÁGINAS VISTAS/ TIEMPO TOTAL/ ORIGEN/ DIRECCIÓN IP.

Este documento no es el que fue requerido en fase de prueba ni consigue acreditar que estas fechas de conexión que constan como “enlace directo”

se correspondan con las activaciones de la casilla del boletín realizadas presuntamente por el reclamante, ya que: (i) constando varios códigos identificadores de la conexión, no puede acreditarse con este documento que las conexiones que aparecen como “enlace directo” hayan sido realizadas por el reclamante (puesto que constan varios números de ID diferentes, y no se aportan los logs de la aplicación que pudieran acreditar cual corresponde al reclamante), (ii) y no se aportan tampoco los logs ni acreditación alguna que justifique que el “enlace directo” tuviera como objeto activar la baja o alta de la casilla del boletín de noticias.

Además, la recurrente sigue sin aportar la documentación técnica sobre *“interpretación de dichos logs”* que fue requerida como prueba. Por tanto, se entiende que la recurrente sigue sin aportar la prueba requerida, y sin acreditar que el reclamante activase el alta del boletín, consintiendo con ello la recepción de nuevas comunicaciones comerciales.

La mera coincidencia de las fechas de alta y baja que aparecen en la ficha de cliente con las que se manifiestan por la reclamada y recurrente no prueba que los datos se correspondan con la realidad, dado que: (i) primero, como se ha señalado, no existen evidencias que permitan constatar que los datos contenidos en la ficha del cliente no se pueden modificar manualmente por la empresa; (ii) y, aunque coincidan las fechas, los datos que aparecen en la ficha de cliente del documento 4 no prueban que exista esta trazabilidad, pues no se aportan los logs de la aplicación que podrían acreditar que dichas anotaciones se han realizado por el reclamante y se generan de forma automática al activar el alta del boletín de noticias y ofertas.

Cabe recordar, al respecto, que la empresa ha mantenido desde el inicio del procedimiento, insistiendo en ello en el apartado 2 de su recurso, que no puede aportar la acreditación del consentimiento de estas altas manifestado al marcar la casilla del referido boletín, dado **que su área web no dispone de un mecanismo automático que documente y registre automáticamente todas las altas y bajas que presuntamente se accionan al marcar la casilla del boletín**. Mantiene que no es necesario hacerlo, puesto que los servicios y la contratación se realizan online. Por lo que, de ser ciertas las propias manifestaciones de la recurrente, es posible que el propio sistema no esté generando los logs a los que se refería el acuerdo de prueba, incumpliendo con ello su deber de registrar y documentar el consentimiento al que nos hemos referido anteriormente.

- Lo mismo cabe aplicar respecto a alegación realizada en el apartado 6 del recurso, donde la recurrente insiste en que contestó correctamente al requerimiento de aportar prueba de la *“dirección IP desde la que se realizó el registro como cliente a nombre del reclamante, y las peticiones de alta formuladas por el mismo desde su cuenta a las que se*

refieren en su escrito”, señalando de nuevo que: “en la ficha de cliente del Documento 4 aparecen las “conexiones a nuestro sitio web, IPS incluidas”.

Se comparten al respecto los argumentos señalados por la Resolución en torno a que el Documento 4 sí informa de las direcciones IP registrados por cada conexión al sistema. Pero los datos que se contienen en el apartado de “conexiones” de la ficha de cliente no ofrecen resultados concluyentes que permitan determinar que desde la dirección IP desde la que se realizó el registro de cliente para comprobar si ésta coincide con aquellas desde las que se pudo solicitar el alta y baja del servicio, lo que, en su caso, sería un indicio de que podrían haber sido realizadas por el reclamante, que por sí solo tampoco sería determinante.

- Por tanto, cabe confirmar la valoración de la prueba realizada en el Fundamento de Derecho III de la Resolución, que valoró conjuntamente las pruebas a las que se refieren los apartados 5 y 6 del recurso, en la que se hizo constar lo siguiente:

<<-Habiendo sido requerida la aportación de la “captura de pantalla de sus sistemas donde se visualicen los logs de las solicitudes de la parte reclamante de alta en la suscripción de los boletines de noticia, e interpretación de dichos logs”, por considerar que la ficha de cliente que se aportó en las alegaciones no constituye una prueba objetiva de la veracidad de los datos que constan en las mismas, la reclamada no aporta dichos logs, limitándose a aportar de nuevo un pantallazo de la “ficha de información del cliente MG” como documento 4, de su sistema informático.

En dicha ficha aparecen los datos de conexiones asociadas a diferentes IPS, sin explicación alguna de a qué se corresponde el ID, y en cualquier caso, por qué las 3 conexiones que aparecen realizadas en las fechas en las que presuntamente se activó el boletín (22-2-23, 23-3-23 y 25-3-23) constan con la única denominación de “enlace directo”, de lo que no puede deducirse que su contenido fuera la activación del alta. Por tanto, no se aporta prueba alguna de la certeza informática de haber activado el alta en ninguna de las 3 ocasiones.

En concreto, no se acredita que el reclamante marcase la casilla del boletín durante el proceso de compra del ordenador portátil. >>

Cuarto: Sobre el nuevo documento aportado con el recurso (Documento 6).

Por otra parte, la recurrente aporta un nuevo documento, Documento 6, que fue requerido y no aportado al procedimiento sancionador, realizando alegaciones al respecto del mismo en el apartado 7 del escrito de recurso.

El mencionado Documento 6 consiste en una captura de pantalla del área de cliente al que se accede tras iniciar sesión en la web de allinzone.es, previo registro del mismo, en cuya parte inferior se observa que consta una casilla en la que se puede activar y desactivar la recepción del boletín de noticias y ofertas comerciales, tal y como señaló

la empresa en el procedimiento originario. No se aporta acreditación de la fecha a la que corresponde dicha captura.

Dicho documento y las alegaciones basadas en el mismo, no pueden ser tenidos en cuenta en la presente Resolución, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 118.1º de la LPACAP, que dispone lo siguiente:

“Artículo 118. Audiencia de los interesados.

1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.

No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado”.

Es evidente que en este caso no procede actuar conforme a lo establecido en el primer párrafo de este artículo 118.1º de la LPA, referida a *“poner de manifiesto el mismo a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes”* toda vez que en este supuesto solo hay un interesado y es la propia recurrente, que ha aportado este documento que no se aportó al expediente originario-pese a haberse requerido en fase de prueba y señalado que no se había aportado el mismo en la Propuesta de Resolución del expediente-”. Dicho párrafo sería aplicable de haber sido otro interesado o la administración quien pretendiera incorporarlo al procedimiento en fase de recurso.

Cabe aclarar también, que no estamos en presencia de la alegación de un “hecho nuevo”, toda vez que el documento 6 pretende acreditar un hecho -la posibilidad existente dentro del área web del cliente en ALLINZONE de activar y desactivar la casilla del boletín- que ya había sido alegado por la recurrente en sus alegaciones al acuerdo de inicio, si bien no había aportado prueba alguna de ello. Así pues, constan los siguientes antecedentes en el expediente originario:

- En sus alegaciones al acuerdo de inicio señaló como motivo principal de defensa que el reclamante había activado el alta del boletín de noticias y ofertas comerciales al acceder a su área de cliente web, y por ello había vuelto a recibir correos electrónicos de carácter comercial.

No obstante, en su escrito de alegaciones al acuerdo de inicio la empresa únicamente aportó la captura de pantalla de la página de registro de nuevo cliente -donde aparece la mencionada casilla del boletín que solicita la remisión de ofertas comerciales- pero no aportó la página del área de cliente, a la que se accede tras haber iniciado sesión. Se comprobó además, mediante Diligencia unida al procedimiento el 18-1-24, que ambas páginas (registro e inicio de sesión) no eran las mismas. Por tanto, no acreditó en sus alegaciones al acuerdo de inicio que existiera posibilidad real de activar el boletín desde el área de cliente.

- Por este motivo, en el acuerdo de prueba de 18-1-24 se le requirió para que se aportase acreditación de que, era posible activar el alta del boletín desde el área de cliente web, al que se accede una vez se ha registrado el cliente, tras iniciar sesión, requiriendo la aportación de un *“Informe acerca del proceso de registro para darse de alta y baja de la suscripción del boletín de noticias que dio lugar a la remisión de las comunicaciones comerciales remitidas al reclamante. Deberán adjuntarse pantallazos, detallando cada paso a seguir por los contratantes del servicio”*.
- Pero al contestar al requerimiento de prueba, la recurrente aportó en fase de prueba dos documentos que no lograban acreditar que existiese esta posibilidad de activar el alta desde el área web (Documentos 1 y 3), lo que se puso de manifiesto expresamente en la Propuesta de Resolución del expediente, señalando los motivos por los que se consideraba que estos documentos no lograban acreditar esta cuestión, señalando lo siguiente:

A) Respecto al Informe del proceso de registro en la web aportado como Documento 1, aportado de nuevo al presente recurso:

<< La reclamada detalla y explica en el documento 1 del escrito de 24 de enero de 2024, cómo es el proceso de contratación online a través del registro en web, manifestando que la solicitud del alta y baja de las comunicaciones comerciales se realiza en todos los casos de forma voluntaria por cada cliente, cliqueando la opción del llamado “boletín de noticias y ofertas comerciales” (en adelante, el boletín) que surge antes de finalizar el proceso de compra (paso 6)

No obstante, no se aporta el pantallazo de ese paso 6, que es precisamente el determinante, en el que el cliente decide voluntariamente recibir el citado boletín, ni tampoco lo que sería más relevante para probar sus afirmaciones, puesto que no presenta justificación alguna de que el reclamante dio su consentimiento a la recepción de comunicaciones comerciales, cliqueando dicha opción. (...)>>.

B) En segundo lugar, respecto al Documento 3, se señaló que se había presentado, de nuevo, la captura de pantalla de la página de registro y no la referida al área de cliente, señalándose lo siguiente:

<<Tampoco se ha logrado acreditar que exista la posibilidad de activar el alta del boletín desde el área del cliente web, como afirma la reclamada que hizo el reclamante posteriormente. De los documentos y pantallazos aportados se deduce que la página de registro inicial se puede activar el boletín, pero no desde la página de inicio de sesión (diligenciada por esta Agencia y unida al procedimiento el 18 de enero de 2024). Y no se ha aportado tampoco pantallazo del área del cliente que permita certificar la posibilidad de activar este link de alta del boletín.(...)>>

- Y pese a realizarse tal valoración en la Propuesta de Resolución, la ahora recurrente no aprovechó el nuevo plazo de alegaciones concedido, y volvió a aportar los mismos documentos en sus alegaciones a la Propuesta de Resolución.
- Por este motivo, el Fundamento de Derecho III de la Resolución la Resolución confirmó la valoración de la prueba realizada en la Propuesta de Resolución, y determinó que la posibilidad de solicitar el alta no quedaba acreditada con estos documentos 1 y 3.
- En definitiva, pese a haberse señalado hasta en tres ocasiones la necesidad de aportar esta prueba -acuerdo de prueba, propuesta de resolución y resolución- no es hasta la interposición del presente recurso cuando la recurrente ha aportado la prueba que podría acreditar que existe una posibilidad real de que cada cliente registrado en la web allzone.es pudiera activar el alta y baja del boletín de noticias y ofertas comerciales al acceder a su área de cliente web.

En concreto, la recurrente hace referencia a esta cuestión el apartado 7 del recurso, y **aporta un nuevo documento (documento 6) que estaba en disposición de aportar y no aportó al procedimiento originario**, señalando que: *“*Además adjuntamos documento correspondiente al área de clientes donde se puede ver específicamente el lugar del cual el cliente puede activar y desactivar su consentimiento a recibir o no comunicaciones comerciales desde la web reclamada. Prueba que según sus ALEGACIONES no habíamos documentado de manera correcta en las anteriores pruebas aportadas. (DOC6)”*

Se ha comprobado que dicho Documento 6, se corresponde con la captura de pantalla del área de cliente al que éste puede acceder, una vez se inicia sesión en la web allzone.es, y que es cierto el hecho manifestado por la reclamada, de que desde el apartado de “mi cuenta” es posible activar la referida casilla de alta en el boletín de noticias y ofertas comerciales.

Ahora bien, al tratarse el documento 6 citado de un documento que estaba a disposición de la recurrente desde el inicio del procedimiento (dado que se corresponde con la captura de su propia área de cliente web), y, por tanto, pudo haber sido aportados en el trámite de alegaciones que le fue concedido (tras las alegaciones al acuerdo de inicio y a la propuesta de resolución, e incluso al contestar al requerimiento realizado por el acuerdo de prueba) no puede considerarse como “hecho nuevo”, y debe ser inadmitido.

Y por otra parte, cabe señalar, que en el caso de haber sido admitido, dicha captura de pantalla no aparece fechada, por lo que no se acredita que esta configuración estuviera activada y fuera posible marcar esta casilla desde el área de cliente a la fecha a la que se refieren los hechos de este expediente.

De todo lo expuesto se deduce que, no cabe tener en cuenta dicho documento 6, en aplicación de la regla prevista en el artículo 118.1º de la LPACAP.

A mayor abundamiento, debe señalarse que en caso de haber sido tenido en cuenta, de su valoración no se deduciría la anulación de la **resolución recurrida, cuyo pronunciamiento debe ser confirmado íntegramente**, toda vez que:

- No existe defecto de forma ni de fondo en la valoración de la prueba realizada al respecto de esta posibilidad de marcar la casilla de alta en el boletín, puesto que la Resolución consideró no acreditado este hecho, y para ello tuvo en cuenta todos los documentos aportados hasta el momento en el procedimiento, entre los que no se encontraba el que se aporta ahora como Documento 6 en la fase de recurso.
- Porque, incluso considerando probado el hecho de que fuera posible marcar el alta del boletín desde el área de cliente web, **ello no acredita que el reclamante hubiera accionado este mecanismo de alta en las dos ocasiones que señala la reclamada** (22 y 25 de marzo de 2023). Consentimiento, que como se ha dicho y reiterado, corresponde documentar y acreditar a la reclamada, que ha reconocido que no dispone de un mecanismo que permita reflejar y archivar los consentimientos que se manifiestan digitalmente al activar las referidas solicitudes de alta y baja que cada cliente realiza al marcar dicho boletín.

Así pues, tal y como se señaló en el Fundamento de Derecho IV de la Propuesta de Resolución, y el Fundamento de Derecho III de la Resolución:

<<< Tampoco se ha logrado acreditar que exista la posibilidad de activar el alta del boletín desde el área del cliente web, como afirma la reclamada que hizo el reclamante. De los documentos y pantallazos aportados se deduce que la página de registro inicial se puede activar el boletín, pero no desde la página de inicio de sesión (diligenciada por esta Agencia y unida al procedimiento el 18 de enero de 2024). Y no se ha aportado tampoco pantallazo del área del cliente que permita certificar la posibilidad de activar este link de alta del boletín.

Pero, lo que es más importante, es que no se ha acreditado que el reclamante haya prestado su consentimiento a recibir estas comunicaciones comerciales, sea cual fuere la vía de alta o activación, el cual debe estar documentado y en poder de la reclamada.

Así pues, de acuerdo con lo mantenido de forma reiterada por la jurisprudencia, en Sentencias como la SAN 2875/2016, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de 15 de julio de 2016, que mantiene lo siguiente:

“En cuanto a la impresión del registro de pantalla en la página web www.lotonazo.com. en el año 2005, lo cierto es que esta Sala ha declarado en la Sentencia de 9 de abril de 2008 -recurso nº.235/2006 -, que los pantallazos o reflejos informáticos no acreditan la prestación del consentimiento: “...no se trata más de un simple “pantallazo” informático, que nada acredita ni aporta ninguna información relevante a la hora de poder acreditar el consentimiento del titular de los datos”. En igual sentido se pronuncia la Sentencia también de esta Sala de 17 de marzo de 2015 -recurso nº. 103/2014”.>>

Por todo lo expuesto, se considera que la Resolución impugnada es acorde a derecho, tanto desde el punto de vista formal como de fondo, a la vista de que el recurso únicamente aporta un nuevo documento que no puede ser tenido en cuenta por no

referirse a hechos no alegados en el procedimiento originario, no siendo aportados al mismo pese a disponer de los mismos y haber sido requerido de su aportación. Pero además, aunque fuera cierto que existía la posibilidad de que el reclamante solicitase el alta del boletín de noticias y ofertas comerciales desde el área de cliente, ello no acreditaría que el reclamante hubiera utilizado esta posibilidad en las dos ocasiones que señala la reclamante.

Esto es, lo relevante en el procedimiento es acreditar que la empresa prestadora del servicio que remitió las ofertas comerciales cumpliera con el requisito de consentimiento previo al que se refiere el artículo 21.1 de la LSSI, y en el presente supuesto, no se han aportado evidencias objetivas que permitan constatar que el reclamante al que remitió los 13 correos electrónicos de contenido comercial que constan unidos al presente procedimiento, hubiera solicitado la remisión de los mismos, activando la casilla de este boletín desde su área de cliente en las fechas indicadas. Por tanto, a falta de acreditación de este consentimiento, cabe considerar que la remisión de estas comunicaciones se hallaba prohibida, incurriéndose en una infracción continuada del artículo 21.1 de la LSSI, para la que está prevista la imposición de una sanción de multa, en los términos expresados en la Resolución del procedimiento.

III

Solicitud de suspensión de la ejecución

Por otra parte, el suplico del recurso de reposición presentado realiza una solicitud de paralización de la ejecución de la resolución recurrida, manifestando lo siguiente:

“En base a ello, SUPLICO que, acogiendo nuestras alegaciones, reponga la resolución que se recurre, estimado el recurso, dictando otra por la que se deje sin efecto la sanción impuesta, y en todo caso PARALICE LA EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN HASTA AGOTAR TODA VÍA ADMINISTRATIVA O CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.”

La parte recurrente está solicitando que se paralice la ejecución hasta agotar la vía administrativa o contencioso-administrativa, pero no concurren las circunstancias que se exigen legalmente para que acordar esta suspensión, por lo siguiente:

a) Respecto a la suspensión hasta agotar la vía administrativa.

No procede acordar la suspensión cautelar de la resolución recurrida en vía administrativa puesto que las resoluciones sancionadoras no son ejecutivas hasta que no se agota la vía administrativa.

Así pues, si bien es cierto que la regla general en derecho administrativo es que de acuerdo con el artículo 117.1º de la LPACAP: *“La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado”*, esta ejecutividad inmediata no se aplica cuando las resoluciones son sancionadoras, respecto a las que el artículo

90.3º de la LPACAP sobre **“Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores”** establece lo siguiente:

“3. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.

Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha suspensión cautelar finalizará cuando:

a) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso-administrativo.

b) Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo:

1.º No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada.

2.º El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella.”

b) Respecto a la suspensión cautelar hasta agotar la vía contencioso-administrativa.

Cuestión distinta es si se puede acordar la suspensión cautelar de la resolución firme en vía administrativa, que se produciría una vez transcurran los plazos señalados desde la notificación de la resolución del presente recurso, en cuyo caso cabe aplicar lo dispuesto en el Artículo 90.3.a) de la LPACAP, que señala lo siguiente:

Esta posibilidad requiere, por tanto, que la parte recurrente comunique expresamente su intención de interponer recurso contencioso-administrativo -lo que no se ha realizado en el escrito de recurso- y, a su vez, que acredite que ha interpuesto el mismo en el plazo de dos meses, en los términos que puso de manifiesto la parte dispositiva de la Resolución recurrida:

“Conforme a lo previsto en el art. 90.3 a) de la LPACAP, se podrá suspender cautelarmente la resolución firme en vía administrativa si el interesado manifiesta su intención de interponer recurso contencioso-administrativo. De ser éste el caso, el interesado deberá comunicar formalmente este hecho mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, presentándolo a través del Registro Electrónico de la Agencia [<https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/>], o a través de alguno de los restantes registros previstos en el art. 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. También deberá trasladar a la Agencia la documentación que acredite la interposición efectiva del recurso contencioso-administrativo. Si la Agencia no tuviese conocimiento de la interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, daría por finalizada la suspensión cautelar.”

En el supuesto presente, el recurso de reposición presentado no aporta acreditación de haber interpuesto recurso contencioso-administrativo. Tampoco

consta comunicación alguna posteriormente realizada al respecto. Por lo que no procede acordar la suspensión cautelar de la resolución firme en vía administrativa en este momento, sin perjuicio de acordarse posteriormente cuando se acredite la interposición del mencionado recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo que se señala en la parte dispositiva de la presente resolución.

IV

Conclusión

En consecuencia, en el presente recurso de reposición, se considera que la parte recurrente no ha aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada, por lo que cabe confirmar la misma.

V

Resolución extemporánea

Debido a razones de funcionamiento del órgano administrativo, por ende no atribuibles a la parte recurrente, hasta el día de la fecha no se ha emitido el preceptivo pronunciamiento de esta Agencia respecto al presente recurso.

De acuerdo con lo establecido en el art. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) el sentido del silencio administrativo en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones es desestimatorio.

Con todo, y a pesar del tiempo transcurrido, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, según dispone el art. 21.1 de la citada LPACAP.

Por tanto, procede emitir la resolución que finalice el procedimiento del recurso de reposición interpuesto.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos **RESUELVE**:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por **ALL IN DIGITAL MARKETING, S.L.** contra la resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 10 de septiembre de 2024, en el expediente EXP202309925.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a **ALL IN DIGITAL MARKETING, S.L.**

TERCERO: Advertir al sancionado que la sanción impuesta deberá hacerla efectiva una vez sea notificada la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98.1.b) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de pago voluntario que señala el artículo 68 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación con el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, mediante su ingreso en la cuenta restringida nº ES00 0000 0000 0000 0000, abierta a nombre de la Agencia Española de Protección de Datos en el Banco

CAIXABANK, S.A. o en caso contrario, se procederá a su recaudación en período ejecutivo.

Si la fecha de la notificación se encuentra entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar el pago voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si se encuentra entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo del pago será hasta el 5 del segundo mes siguiente o inmediato hábil posterior.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la presente Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa conforme al art. 48.6 de la LOPDGDD, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la referida Ley.

Finalmente, se señala que conforme a lo previsto en el art. 90.3 a) LPACAP, se podrá suspender cautelarmente la resolución firme en vía administrativa si el interesado manifiesta su intención de interponer recurso contencioso-administrativo. De ser éste el caso, el interesado deberá comunicar formalmente este hecho mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, presentándolo a través del Registro Electrónico de la Agencia [<https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/>], o a través de alguno de los restantes registros previstos en el art. 16.4 de la citada LPACAP. También deberá trasladar a la Agencia la documentación que acredite la interposición efectiva del recurso contencioso-administrativo. Si la Agencia no tuviese conocimiento de la interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, daría por finalizada la suspensión cautelar.

180-21112023

Loreno Cotino Hueso
Presidente de la Agencia Española de Protección de Datos